

1507511-58.2021.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507511-58.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507511-58.2021.8.26.0577 - Controle nº 2022/000482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS JUNIO CLAUDINO DE FRANÇA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

ELIAS JUNIO CLAUDINO DE FRANÇA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 330, do Código Penal, bem como artigos 309 e 311 da Lei nº 9.503/97, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 16h35, na Av. Pedro Friggi, Vista Verde, nesta cidade, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos; dirigiu automóvel, em via pública, sem ser habilitado para tanto; e trafegava em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano.

Apurou-se que o acusado, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, assumiu a condução do veículo Fiat Palio da namorada. Ao avistar a viatura da guarda municipal, acelerou o veículo e empreendeu fuga, avançando semáforos vermelhos, passando sobre a calçada e realizando manobras proibidas e perigosas. Os guardas foram ao encalço do veículo, emitiram ordens de parada ao condutor, que as desobedeceu e continuou em fuga, imprimindo velocidade excessiva em locais de grande movimentação e aglomeração de pessoas. Quando parou em frente à casa da namorada, desembarcou e abandonou o veículo em movimento, o carro parou ao bater em um pilar de ferro.

A denúncia foi recebida, sendo o acusado citado e interrogado.

Em juízo foram ouvidas as testemunhas.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência.

A defesa disse que deve ser absolvido quando ao crime do artigo 309, eis que a conduta foi absorvida pelo segundo delito. No mais a pena deve ser a mínima e substituída. O regime o aberto e apelar em liberdade.

Relatei.

Decido.

A ação procede parcialmente.

Vejam os.

O acusado não foi ouvido na fase policial.

Em juízo disse que estava na condução do veículo quando ouviu os guardas municipais mandaram parar e descer do carro. Não obedeceu e fugiu. Realmente passou por sinais vermelhos. Não colidiu contra outros carros e não trafegou sobre a calçada. Não é habilitado, por isso não parou. Mostrou-se arrependido.

Já os guardas quando inquiridos contaram que o acusado não atendeu à ordem de parada, colocando-se em fuga pelas ruas da cidade. Imprimiu velocidade excessiva ao veículo passando inclusive por locais de grande movimento de pessoas e veículos. Contaram que o acusado passou a fugir desde que avistou a viatura.

A namorada do acusado disse no Distrito Policial que o acusado pegou as chaves do carro sem o seu consentimento.

A testemunha Suzana, também no Distrito Policial, disse que Elias lhe ofereceu carona. Uma viatura da guarda civil se aproximou do carro e "pediu" que parasse. Ele desobedeceu a ordem e passou a dirigir em alta velocidade, desviando de carros, dirigindo na contra-mão de direção. Quando chegou em casa, Elias não desligou o carro e saiu em desabalada carreira, fugindo dos guardas.

Provas estão a materialidade e autoria.

A certidão de fls. 60 confirma que o acusado não possui CNH válida.

Tratando do dispositivo penal inserido no Código de Trânsito (artigo 309), que se refere à direção inabilitada de veículo, na via pública, entende, o penalista Paulista, Damásio E. de Jesus, que se trata de crime de lesão e de mera conduta. Aclarando tal posicionamento, afirma o mestre Damásio que, "a direção sem permissão ou habilitação é crime de lesão e de mera conduta. A condução inabilitada, isoladamente conduz só ilícito administrativo (Código de Trânsito, art. 162). Transforma-se em crime, somente quando o motorista dirige de forma anormal, rebaixando o nível de segurança exigido pelo Estado, assim, expondo um número indeterminado de pessoas a perigo de dano (perigo coletivo, comum). Nova formulação típica atende ao reclamo da doutrina mundial no sentido da discriminação da infração do antigo art. 32 da Lei das Contravenções Penais, transformando os fatos, quando praticados sem risco a incolumidade pública, em simples e lícito administrativo" (em "Natureza Jurídica dos Crimes de Trânsito", pág. 34, Ed. Paloma, São Paulo, 1998).

Invocando lição anterior sua, insiste o consagrado mestre afirmando que, "realmente, tratando-se de crime contra a incolumidade pública, a simples direção de veículo sem habilitação, sem risco a segurança coletiva, não afeta o bem jurídico, qual seja, a segurança pública no que concerne à circulação de veículos. De modo que a sua apenação criminal, quando a conduta não oferece risco, ofende o princípio constitucional lesividade. Não é suficiente a simples tipicidade formal, adequação do fato ao modelo legal. É preciso que se atenda à regra da tipicidade material: o fato só é típico quando ofende ou expõe o bem jurídico a perigo de dano" (ob. cit., pág. 34).

De minha parte, entendo que não se pode exigir a presunção absoluta da causação de perigo, a inexigir a prova da existência de estado de perigo para a incolumidade física de terceiros.

Há que se estudar, em cada caso, se a referida ação projetou no campo da realidade fática, algum tipo de perigo para o bem jurídico tutelado, vale dizer, a incolumidade alheia.

Aqui não há dúvida de que o acusado conduzia seu veículo sem habilitação e com real perigo de dano.

Com efeito, o acusado confirmou que era ele o condutor do veículo, sendo certo que não obedeceu ao sinal de parada, passando em cruzamentos e local com diversos pedestres, tendo empreendido fuga.

Ora, não há como negar que o acusado, ao imprimir velocidade incompatível com a segurança, expôs a risco ele próprio, o carona e os demais motoristas que eventualmente estivessem cruzando a pista naquele momento.

Não é por outro motivo que se trata de infração de trânsito classificada como gravíssima.

Da análise dos autos, denota-se claramente que houve exposição a dano potencial a incolumidade de outrem, configurado o delito previsto no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

Anoto que não há falar em absorção eis que os objetos jurídicos protegidos são distintos, de modo que a mera elementar do tipo do artigo 309 não é capaz de absorver, por inteiro, o tipo penal do artigo 311, ambos do C.T.B.

Passo à desobediência.

O art. 330 dispõe: "Desobedecer a ordem legal de funcionário público".

Restou fartamente demonstrada nos autos a ordem, por meio dos depoimentos colhidos. Aqui bom dizer que é certo que a ordem de parada foi dirigida ao acusado quando apenas trafegava pela via, como informado pela testemunha Suzana.

Ocorre que a Guarda Municipal não poderia determinar, na hipótese, que o motorista parasse seu veículo.

Assim decidiu o S.T.J., no Recurso Especial 1977119.

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras "polícias municipais", mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte – apesar das investidas em contrário – por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal. 2.

Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil – em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência – estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais – apesar da sua relevância – não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar – em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais – o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para "Polícia Municipal". Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese. Recurso especial provido. "

Percebe-se que aqui não há crime eis que não havia ordem legal.